

※ 들어가기 ※

- 먼저, 무더운 여름 불규칙한 날씨와 싸우며 2차 시험을 치루신 수험생 여러분들, 고생 많으셨습니다. 노력하신 만큼 좋은 결실이 있으시길 바랍니다.
- 본 자료는 강사의 개인적인 사건이며 출제자의 의도, 논점과 다소 다를 여지는 있음을 참고하시기 바랍니다.

※ 총 평 ※

- 이번 2차 민소 문제는 작년(51회) 공동소송 부분이 다수 기출된 점을 감안하여 그 외 기본서의 전 범위에 걸쳐 고루 출제하려는 경향이 두드러졌으며 중요한 논점 위주로, 기본서의 내용을 정확히 이해하고 있는지에 출제의 주안점을 둔 것으로 판단됩니다. 나아가 최근 판시(2012 ~ 2013년)를 기초로 문제를 구성함으로 최근의 출제경향을 짐작하게 합니다.
- 대부분의 논점은 A급 ~ B+급 이상에서 출제되었고 특별히 지엽적인 논점은 출제되지 않았습니다. {주된 논점은 국제재판관할, 소송계약 및 지적의무, 추후보완항소, 청구의 변경, 부진정예비적병합(判例), 일부판결과 판단누락, 소송행위 철회와 의사의 하자 등으로 보입니다}
- 대부분 기초 및 실전 CS에서 다루었던 논점으로 동차생 분들도 끝까지 포기하지 않으셨다면 생각보다 좋은 점수를 기대할 수 있지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다.
- 실제 무난한 문제가 출제될 경우 ‘정확한 논점의 파악’, ‘문제점(논의의 배경, 논점의 필요성), ‘判例의 정확한 소개’, ‘충실한 검토’ 등에서 생각 이상의 점수 차이가 날 수 있습니다.

※ 문항 별 시범답안 - key-word ※

- 간략히 key-word 위주로 작성해 보았습니다. 참고하세요.

[문제-1]

I. 논점의 정리

1. 설문(1) : 국제재판관할에 관한 항변이 적법한지 묻고 있는바 ① 관할합의의 종류(전속적인지), 주관적 범위 ② 전속적 합의관할이 다른 나라에 제소할 경우까지 효력이 미치는지(判例), ③ 국내 국제재판관할이 있는지 국제사법 2조의 검토(·· 직권조사사항)
2. 설문(2) : ① 소송계약의 법적성격(직권조사사항인지), ② 지적의무 위반인지(判例 전제)

II. 설문(1)의 해결 - 국제재판관할

1. 국제재판관할 일반론 (압축적시)

- 의의 / 취지
- 종래의 논의
- 입법적 해결 - 국제사법 제2조 / 수정역추지설 반영(타당)

2. 관할합의의 종류

- (1) 문제점
 - 전속적, 부가적 합의 개념 포섭하고, 설문은 ‘의사가 불명’하여 검토가 필요함을 언급
- (2) 견해의 대립
- (3) 判例의 태도
- (4) 검토
 - 通說, 判例 타당(당사자의 합리적 의사가 그러함)
 - 제8조 후단에 따라 의무이행지, 따라서 전속적 합의

3. 주관적 범위 - 승계시

- (1) 문제점
 - 포괄승계(ex 상속) : 당연히 합의 승계됨(·· 권리, 의무 승계)
 - 특정승계 : 爭
- (2) 通說, 判例1)
 - 물권적 권리 : 승계x(·· 물권법정주의 反(민185조), 공시방법x)
 - 채권적 권리 : 승계0(·· 계약자유 원칙, 공시방법0)
- (3) 설문의 경우
 - 승계됨

1) 대법원은 “관할합의에 따른 관할변경은 실체법적으로는 권리행사의 조건으로서 그 권리관계에 불가분적으로 부착된 실체적 이행의 변경이라고 보고, 지명채권과 같이 그 권리관계의 내용을 당사자가 자유롭게 정할 수 있는 경우라면 당해 권리관계의 특정승계인은 그와 같이 변경된 권리관계를 승계한 것”이라고 판시하였습니다(대법 2006. 3. 2. 2005마902 판결 참조)

4. 전속적 합의관할이 다른 나라에 제소할 경우까지 효력이 미치는지 여부

- (1) 判例의 태도(대판 2008. 3. 13. 2006다68209 판결)
- (2) 검토 및 설문의 경우
 - 관할합의는 합의한 그 나라에서 재판관할이 있음을 전제로 그 효력을 인정함이 타당
 - 乙의 항변은 적법하지 않음
 - 단, 국제재판관할은 직권조사사항(通說, 判例), 간략히 추가 검토 요

5. 국제사법 제2조에 따른 검토

- (1) 토지관할 규정 고려
- (2) 특단의 사정 존부

6. 설문의 (1)의 해결

- 乙의 항변은 적법하지 않고, 아울러 우리나라에 국제재판관할이 있음

III. 설문(2)의 해결 - 소송계약의 법적성격, 지적의무

1. 문제점

- 소송계약의 의의와 허용여부 간단히 언급
- 직권조사사항인지 그 법적성격이 문제됨
- 직권조사사항이라 하더라도 지적의무 위반인지 추가 검토가 필요

2. 법적성격 - 불이행시 효과

- (1) 견해의 대립
 - 사법계약설
 - 의무이행소구설
 - 항변권발생설(通說) - 항변 요
 - 소송계약설 - 직권조사 可

(2) 判例의 태도

- 항변권발생설 but 직권조사 可

(3) 설문의 경우

- 항변권발생설 타당, 설문은 그 항변이 없으나, 判例에 따르면 직권조사 가능
- 단 지적의무(제136조제4항) 위반인지 문제

3. 지적의무 위반인지(제136조제4항)

- (1) 의의 및 취지
 - 간과 명백한 법률적 사항 對의견 진술 기회 부여
 - 기습재판의 금지, 절차적 기본권의 보장(취지)
- (2) 요건
- (3) 내용 : 의견진술기회 부여 / 변론종결 후 발견시 : 변론제개 불가피(법 제142조)
- (4) 의무위반의 효과 : 상고이유0(단, 일반적 상고이유) / 재심사유는x

(5) 判例의 태도 - 지적의무 위반 (대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다80449 판결)

- 당사자들이 부제소 합의의 효력이나 그 범위에 관하여 쟁점으로 삼아 소의 적법 여부를 다투지 아니하는데도 법원이 직권으로 부제소 합의에 위배되었다는 이유로 소가 부적법하다고 판단하기 위해서는 그와 같은 법률적 관점에 대하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 함

4. 설문(2)의 경우

- 항변권발생설 따르면 항변 없으므로 위법
- but 判例 따르면 직권조사 가능 but 지적의무 위반, 위법

IV. 설문의 해결

[문제-2]

I. 논점의 정리

- 1. 설문(1) : 乙의 항소가 추후보완항소(173조)로 보아 적법한지
- 2. 설문(2) : 백지문서에 제358조가 적용되는지(증명책임 법리 오인 여부)

II. 설문(1)의 해결 - 추후보완항소(173조)

1. 문제점

- 공시송달의 효력 간단히 검토(보충성에 반하는 공시송달인지 불분명)
- 적법하다면, 항소기간이 경과한 것은 명백하나 항소의 종류는 직권조사사항으로 추후 보완항소로 적법한지 검토 요

2. 공시송달의 효력(判例, 通說)

- 가사 보충성에 반하여 위법해도 그 효력은 유효²⁾

3. 추후보완항소(173조)

- (1) 의의 및 취지
- (2) 요건
- (3) 추후보완 사유 - 공시송달의 경우
 - 判例의 태도 : 원칙 0 / 단 예외 있음
- (4) 추후보완 기간
 - 判例의 태도³⁾

2) 學說 및 判例는 일관되어 공시송달에 따른 편취판결의 효력에 대해 당원무효는 아니며 위법하나 유효하다는 입장이다. ①공시송달은 법원의 재판형식인 명령절차에 의해 진행되어 그 보충성의 요건에 흠이 있더라도 이를 당원무효로 볼 수 없고, ②나아가 입법자는 위 판결이 유효하며 확정될 수 있는 전제하에서 제451조 제1항 제II호의 재심사유로 정해놓았기 때문이다.

3) 당사자가 책임질 수 없는 사유(즉, 장애사유)가 없어진 날로부터 2주 이내에, 다만 그 사유가 없어질 당시 외국에 있는 당사자인 경우에는 30일 이내에 게을리 한 소송행위를 하여야 한다. 설문과 같이 공시송달에 의한 판결의 송달사실을 과실 없이 알지 못한 경우에 위 2주일 또는 30일의 기간이 개시되는 시점에 대해서, 判

4. 검토 및 설문(1)의 경우

- 일반항소 기간은 경과하였으나, 추후보완항소로 적법

III. 설문(2)의 해결 - 백지보충문서에 제358조 적용여부

1. 증명책임의 원칙

- 법률요건분류설(通說, 判例)을 중심으로 설명하고 설문에 적용

2. 사문서 형식적증거력 및 실질적 증거력의 추정

- 사문서의 추정(제358조)내용, 성격 설명
- 358조가 적용되는 경우, 실질적 증거력 추정(判例)
- 단, 설문의 경우 백지보충문서에 358조가 적용되는지 문제됨

3. 견해의 대립

- 배제설 : 작성자 보호, 실무 반영
- 적용설 : 법문상 배제근거 없음

4. 判例의 태도 (대법원 2013. 8. 22. 선고 2011다100923 판결)

- 判例(배제설) : 정당한 보충권한에 의하여 기재된 것이라는 점을 채권자가 별도로 증명하여야 함

5. 검토 및 설문의 경우

- 배제설(判例) 타당
- 적용설에 따르면 358조 적용, 추정되므로 피고의 반증이 없어 적법
- 배제설에 따르면 358조 적용x, 정당한 권원에 대한 증명이 없음
- 결국, 사문서의 진정성립과 백지보충권에 관한 증명책임에 관한 법리를 오해 하고,논리와 경험의 법칙에 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 있음.

IV. 설문의 해결

[문제-3]

I. 논점의 정리

1. 설문(1) : ① 청구변경으로 적법한지, ② 병합의 형태, 양립가능 한 청구를 예비적 병합으로 청구할 수 있는지
2. 설문(2) : ① 병합의 형태(선택적 병합인지), ② 일부판결시 재판누락인지

II. 설문(1)의 해결 - 부진정예비적병합

1. 청구변경 적법여부(제262조)

예는 당사자나 대리인이 판결이 있었던 사실을 안 때가 아니라 그 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 안 때, 즉 당해 사건기록의 열람 또는 새로운 판결정보를 영수한 때로 보고 있다(대법 1999. 2. 9, 98다43533).

(1) 의의 및 취지

(2) 청구의 변경인지 - 소송물이 복수인지

- 구이론 - 선택적 병합(청구취지1개, 청구원인 수개)
- 신이론(일분지설, 이분지설) - 목적물 1개, 행위1개 결국 공격방법이 복수일 뿐
- 구이론 타당

(3) 청구변경의 요건 - 청구기초의 동일성

- (3) 설문의 경우 - 추가적 변경으로 적법, 병합의 형태 원칙은 선택적 병합 (∴ 청구취지 1개, 청구원인 수개)

2. 양립가능 한 청구를 예비적 병합으로 청구할 수 있는지

(1) 문제점

- 예비적 병합은 '양립불가능' 원칙(通說, 判例)
- 양립가능 한 청구를 예비적 병합으로 청구시 법원의 조치

(2) 견해의 대립

- 부정설(多) - 병합의 형태에 따라 단순 또는 선택적 병합으로 심판 要
- 긍정설

(3) 判例의 태도

- 원칙 : 불허
- 예외 : 인정(합리적 필요성, 부진정예비적병합)

3. 검토 및 설문(1)의 경우

- 判例 타당(합리적 필요성 있는 경우라면 당사자의 의사 존중 필요)
- 위와 같은 병합형태는 예비적 병합으로 적법함.

III. 설문(2)의 해결 - 선택적 병합과 일부판결의 가부

1. 문제점

- 별소제기 고려 가능하나 중복된 소제기(제259조)가 되어 불가함을 간단히 언급

2. 청구변경의 적부

- 소송물 복수이며(구이론), 청구변경은 적법함

3. 병합의 형태 - 선택적 병합

(1) 判例의 태도 (대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다8365 판결)

- 청구취지를 변경하지 아니한 채 피고가 제1심판결 선고 후 행한 새로운 명예훼손 행위를 청구원인으로 추가한 경우 선택적 병합으로 판시4)

4) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다8365 판결 【손해배상(기)】

[1] 명예훼손행위를 원인으로 한 손해배상청구소송의 제1심판결 선고 후에 그 소송당사자인 피고의 새로운 명예훼손행위가 있는 경우, 위법성조각사유의 유무를 새로운 명예훼손행위 당시의 시점을 기준으로 새롭게 판단하여야 하는지 여부 (적극)

[2] 명예훼손행위를 원인으로 한 손해배상청구소송에서 패소한 원고가 항소심에서 청구취지를 변경하지 아니한 채 피고가 제1심판결 선고 후 행한 새로운 명예훼손행위를 청구원인으로 추가한 경우, 이를 선택적 병합청구로 볼 수 있는지 여부(적극) 및 항소심이 위 추가된 선택적 병합청구에 관하여 아무런 판단도 하지 아니한 것이

(2) 검토

- 청구취지가 동일하고 청구원인이 수개인 경우⁵⁾로 判例 태도 타당

4. 일부판결시 재판누락인지 여부

(1). 문제점

- 일부판결 허용여부 : 불가(∴ 불가분적 결합)
- 재판누락으로 추가판결 대상인지 문제됨

(2). 견해의 대립

- 재판누락설, 판단누락설, 절충설

(3). 判例의 태도 (대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다8365 판결)

- 판단누락설

5. 검토 및 설문(2)의 해결

- 판단누락설 타당
- 甲은 추가판결이 아닌 '항소'를 제기하여 구제받을 수 있음

IV. 설문의 해결

[문제-4]

I. 논점의 정리

1. 설문(1) : ① 청구변경 적법한지, ② 항소심에서의 교환적 변경과 재소금지 적용여부, ③ 최종, 구체적으로 기간을 나누어 재소금지 여부 판단
2. 설문(2) : 형사상 처벌받을 행위 존재 시 항소취하의 효력이 判例 태도 중심 문제됨

II. 설문(1)의 해결 - 부진정예비적병합

1. 청구변경 적법여부(제262조)

- 결국 소송물이 복수고 청구기초의 동일성이 있어 교환적 변경으로 적법

2. 재소의 금지 일반론

- (1). 의의 및 취지
- (2). 요건 및 효과

3. 항소심에서의 교환적 변경과 재소금지 적용여부

- (1) 교환적 변경의 법적 성격
 - 구소취하-신소제기설(결합설, 通, 判, 타당) : 소취하 효력 인정
 - 262조 독자적 소 변경설(호) : 소취하 효력 부정

판단누락에 해당하는지 여부 (적극)

- 5) 청구취지를 변경하지는 않았다는 것은 어느 하나의 행위로라도 위 금원을 인정받으면 된다는 의사로 보임

(2) 재소금지 적용여부

- 긍정설(多, 判, 타당) : ∴ 구소취하 효력 인정, 법원 중국판결 농락 可
- 부정설(독자적 소 변경설)

4. 검토 및 설문(1)의 경우

- 긍정설 타당, 재소금지 저촉 가능
- 단, 2013. 6. 30. 이후 부정경쟁방지 손해청구 부부는 1심에서 청구하지 않은 기간에 관한 것으로 소송물이 동일하지 않은 것이므로 재소금지 저촉x
- 대법원도 설문과 유사한 사안에서 제1심에서 청구하지 않았던 기간에 해당하는 손해배상청구를 한 것이므로 제1심에서 청구하였던 침해금지청구 및 손해배상청구와 소송물이 동일하다고 보기 어렵고 다시 청구할 필요도 있어, 그 청구의 추가가 재소금지의 원칙에 저촉되지 않는다고 판시 (대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결)
- 2013. 6. 30. 까지 : 재소금지 각하
- 이후부분 : 저촉x 본안판단 가능

III. 설문(2)의 해결 - 구속적 소송행위의 효력

1. 문제점

- 취효적 소송행위라면 철회가 가능 but 설문은 여효적(구속적) 소송행위로 그 효력이 문제됨

2. 민법상 109, 110조 유추 취소 가부

(1). 견해의 대립

- 불고려설(채심규정 유추설, 通) : ∴ 절차안정 침해, 명문상 인정근거x
- 고려설(민법규정 유추설)(호)
 - 원칙 : 불고려설 타당
 - 예외 : only 절차안정 무관한 소송행위 유추 인정(ex 소취하, 청구의 포기 인낙, 재판상 화해 등 절차종료행위)

(2). 判例의 태도

- 불고려설("소송행위가 강박에 의한 것이라는 이유로 취소할 수 없다")

(3). 검토

- 불고려설 타당(표시주의, 외관주의 관철)

3. 구속적 소송행위의 철회 가부 - 불고려설의 예외

(1). 원칙 : 철회 不可

(2). 예외 - 형사상 처벌받을 행위(451①5호 유추)

- 확정판결 요구설(주류 判) : only 외형만 존재(의사x) + 유죄확정판결 要
- 확정판결 불요설(이, 타당) : 당사자 가혹(외형만 존재할 필요도 없음)

(3). 判例의 태도 (대법원 2012.06.14. 선고 2010다86112 판결)

- 대법원은 설문과 유사한 사안에서 "어떠한 소송행위에 민사소송법 제451조 제1항 제5호의 재심사유가 있다고 인정되는 경우 그러한 소송행위에 기초한 확정판결의 효력을 배제하기 위한 제심제도의 취지상 재심절차에서 해당 소송행위의 효력은 당연히 부정될 수밖에 없고, 그에 따라 법원으로서 위 소송행위가 존재하지 않은 것과 같은 상태를 전제로 재심대상사건의 본안에 나아가 심리·판단하여야 하며 달리 위 소송행위의 효력을 인정할 여지가 없다."고 판시

4. 검토 및 설문(2)의 경우

- 判例의 태도 타당
- 따라서 항소취하는 무효

IV. 설문의 해결

※마치며 - 2015년의 대비※

□ 주요논점 위주의 출제경향을 어느 정도 지속될 것으로 생각합니다.

- 각 득점 point의 정확한 정리 및 '이해한 것으로 보이는 답안'에 대한 준비가 필요합니다.
- Key-word는 충실히 암기해야 하겠습니다.

□ 최근판례의 정리

- 통상 기본서의 법리를 통해 사례해결이 가능하도록 출제하고 있으나,
- 문제 구성 시, 최근 판시 사례를 참조하는 경향이 강하므로 3년 간 중요한 판시 내용은 직접 그 원문을 확인, 정리할 필요성이 있을 것으로 보입니다.

□ 기본서 및 조문의 정독

- 불의타에 대한 두려움으로 무한정 양을 늘리는 것은 '모든 논점을 불의타'로 만드는 지름길입니다.
- 기본서의 꼼꼼한 정독과 조문의 충분한 이해가 필요할 듯합니다. 감사합니다.